

1500219-19.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500219-19.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2038316/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22928289 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

416/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2038316 - 02º D.P. PIRACICABA, 416/22/922

- 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENILSON CELESTINO DA ROCHA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 21 dias do mês de setembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentadas as testemunhas arroladas em comum pelas partes:

Emerson Santos de Oliveira e Izhar Lucas Garutti Seisdodos.

Ausente o acusado Genilson Celestino da Rocha, o qual foi devidamente intimado, quando do cumprimento do alvará de soltura, conforme certidão de fls.148.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi colhido o depoimento da testemunha (Emerson) pelo sistema virtual.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Izhar.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu foi devidamente intimado e não compareceu nem pessoal e nem virtualmente, DECRETO A SUA REVELIA.

Homologo a desistência das partes em relação à oitiva da testemunha Izhar Lucas Garutti Seisdedos.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiz(a), GENILSON CELESTINO DA ROCHA está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta de 03h56m, na rua Augusto Furlan, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, trazia consigo 59 porções de "crack", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia fora oferecida a fls. 82/88. O réu fora notificado (fls. 95), a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar (fls. 111/112) e a denúncia fora recebida (fls. 120/124).

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografia (fls. 19) e Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 142/144).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Dos fatos

Segundo se apurou, guardas municipais passavam pelo local, conhecido pelo "intenso tráfico de drogas", quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que estava parado na via pública e, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga.

Após breve perseguição, feita abordagem de praxe, em poder do denunciado, numa "pochete" foram localizadas 59 porções de crack, além da quantia de R\$79,65, em espécie.

Informalmente e perante a autoridade policial, o denunciado confessou o delito e alegou "a droga é sua e estava vendendo para manter o vício, pois é usuário contumaz".

Diante das circunstâncias apuradas, localização de drogas em porções individualizadas em poder do denunciado e dinheiro de origem não comprovada, além da confissão, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Com efeito, a testemunha Emerson Santos de Oliveira, guarda municipal, confirmou seu depoimento da na fase policial, oportunidade em que disse que "(...) estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Esplanada, junto a Rua Augusto Furlan, quando a equipe policial avistou um indivíduo que estava na via pública, em local já conhecida por intenso comercio de drogas, sendo que este indivíduo ao avistar os policias saiu em disparada tentando empreender fuga, fato este que chamou a atenção dos policiais. Diante da fundada suspeita, os policiais foram ao encalço deste indivíduo, depois de aproximadamente 100 metros, este indivíduo foi abordado e em revista pessoal foi localizado uma pochete, que estava em sua posse, e em seu interior havia 59 porções de "crack" e R\$ 79,65 reais em notas diversas. Este indivíduo foi identificado por Genilson Celestino da Rocha, que em entrevista informal com os policiais confessou que estava no local na prática do tráfico, que vendia para manter seu vício, ademais manteve-se em silencio" (fls. 04/05)

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo guarda municipal Izhar Lucas Garutti Seisdedos, que afirmou em solo policial que "estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Esplanada, junto a Rua Augusto Furlan, quando a equipe policial avistou um indivíduo que estava na via pública, em local já conhecida por intenso comercio de drogas, sendo que este indivíduo, ao avistar aos policiais, saiu em disparada tentando empreender fuga, fato este que chamou a atenção dos policiais. Diante da fundada suspeita, os policiais foram ao encalço deste indivíduo, depois de aproximadamente 100 metros, este indivíduo foi abordado e em revista pessoal foi

localizado uma pochete em sua posse e em seu interior havia a quantia de 59 porções de crack e R\$ 79,65 reais em notas diversas. Este indivíduo foi identificado por Genilson Celestino da Rocha, que em entrevista informal com os policiais confessou que estava no local na prática do tráfico, que vendia para manter seu vício, ademais manteve-se em silêncio" (fls. 06).

Em juízo, os guardas reiteraram o que haviam declarado em solo policial. Estavam em patrulhamento nas imediações de unidades municipais de saúde quando viram e abordaram o réu em atitude suspeita. O réu tentou fugir ao ver a viatura.

Encontraram drogas com ele, e dinheiro.

Em solo policial, o réu confessou o crime, afirmando que "(...) a droga é sua e que estava vendendo para manter o vício, pois é usuário contumaz." (fls. 07/08).

Em juízo, tornou-se revel.

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito em questão.

A narrativa dos policiais foram firmes e uníssonas em confirmarem que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido nos meios policiais pelo intenso comércio de drogas, quando avistaram um indivíduo na via pública, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, saiu em disparada e tentou fugir, o que chamou a atenção dos guardas. Desconfiados da atitude, conseguiram abordar o sujeito 100 metros adiante e, após realização de revista pessoal, fora localizada uma pochete em que havia 59 porções de "crack" e R\$ 79,65 em notas diversas.

Assim, devidamente comprovada que a droga trazida pelo réu destinava-se à mercancia ilícita.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas municipais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso

Não obstante, o réu confessou a prática delitativa, admitindo que a droga lhe pertencia e que estava realizado o comércio ilícito para manter seu vício.

Salienta-se que a versão apresentada pelo denunciado não afasta o acerto do decreto condenatório. O fato de afirmar ser usuário de drogas não afasta a prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois é comum a comercialização ilícita para o fim de sustentar o próprio consumo.

Destarte, diante do conjunto probatório e da confissão do réu, imperiosa sua condenação pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira fase, pena no mínimo legal.

Concordo com a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar mínimo, considerando que o réu é primário, não possui antecedentes criminais e não há indícios de que se dedica às atividades criminosas e/ou integre organização criminosas.

Regime aberto.

Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com a acusada, consistente em R\$ 79,65 reais (setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com fulcro nos artigos 62, §2º, e 63, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Destarte, requeiro seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos termos acima.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Genilson Celestino da Rocha foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls.82-86), no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta de 03h56, na rua Augusto Furlan, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, Genilson trazia consigo 59 porções de "crack", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ainda segundo a inicial acusatória, guardas civis passavam pelo local, conhecido pelo "intenso tráfico de drogas", quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que estava parado na via pública e, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Após breve perseguição, feita abordagem de praxe, em poder do denunciado, numa "pochete" foram localizadas 59 porções de crack, além da quantia de R\$79,65, em espécie. Informalmente e perante a autoridade policial, o denunciado confessou o delito e alegou "a droga é sua e estava vendendo para manter o vício, pois é usuário contumaz".

Na delegacia o guarda municipal Emerson Santos De Oliveira: "Alega o Guarda Municipal de Piracicaba, ora condutor, que no dia de hoje por volta das 03:56 horas, estavam e patrulhamento de rotina pelo Bairro Esplanada, junto a Rua Augusto Furlan, quando a equipe policial avistou um indivíduo que estava na via pública, em local já conhecida por intenso comercio de drogas, sendo que este indivíduo ao avistar aos policiais saiu em disparada tentando empreender fuga, fato este que chamou a atenção dos policiais. Diante da fundada suspeita, os policiais foram ao encalço deste indivíduo, depois de aproximadamente 100 metros, este indivíduo foi abordado e em revista pessoal foi localizado uma pouchet, que estava em sua posse, e em seu interior havia a quantia de 59 porções de CRACK e R\$ 79,65 reais em notas diversas. Este indivíduo foi identificado por GENILSON CELESTINO DA ROCHA, que em entrevista informal com os policiais confessou que estava no local na pratica do tráfico, que vendia para manter seu vício, ademais manteve-se em silencio." (fls.4-5)

No mesmo sentido as declarações do guarda municipal Izhar Lucas Garutti Seisdedos (Fls.6)

Interrogado em solo policial, Genilson disse que: "a droga é sua e que estava vendendo para manter o vício, pois é usuário contumaz" (fls.7-8).

Juntadas folha de antecedentes e certidões de objeto e pé (fls. 32-33) que comprovam a primariedade do acusado.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 142-144.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido o guarda municipal Emerson Santos De Oliveira, disse que estava em patrulhamento pelo local. O réu visualizou a viatura e tentou correr. Em 100 metros de distância, conseguiram abordá-lo. Em revista, acharam drogas e dinheiro em uma pochete. Indagado sobre o motivo pelo qual correu, o réu disse que era usuário e estava traficando para sustentar o vício. O patrulhamento era entre o centro comunitário e uma UBS, que ficam na mesma rua. Quando avistado, o indivíduo estava parado. Não conhecia o réu. O local é ponto de venda de drogas.

O réu é revel.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal.

Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita.

Segundo disseram os guardas na delegacia, "estavam e patrulhamento de rotina pelo Bairro Esplanada, junto a Rua Augusto Furlan". Teriam, além disso, abordado o réu porque ele "saiu em disparada tentando empreender fuga, fato este que chamou a atenção".

Não se tratava, portanto, de situação flagrante, mas sim uma atuação de policiamento ostensivo dos guardas.

Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de

atuação da Guarda Civil Municipal. Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, logo após a visualização do imputado, eles efetuaram a abordagem imediatamente; o averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância. E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelár.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Tal entendimento foi reforçado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme a decisão, somente em situações absolutamente excepcionais, a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, devendo demonstrar que a ação está diretamente relacionada à finalidade da corporação:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda

municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de se ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal. 3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros. 4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. 5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. 8. É

possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. 12. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1977119 - SP (2021/0391446-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgado em 16/08/2022. DJE 23/08/2022. Grifos nossos).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA NULIDADE EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL

PRELIMINARMENTE a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade em razão da ilegalidade da abordagem por uma dita “atitude suspeita”, da revista pessoal NO RÉU e, conseqüentemente, de todos os atos decorridos na continuidade de sua prisão. Os guardas disseram que não avistaram drogas com o réu, mas sim decidiram abordá-lo porque ele correu.

Temos que toda a ação da guarda que resultou na prisão em flagrante teve origem em uma abordagem e uma revista pessoal ilegal, prova ilícita que contamina todas as outras provas dela decorrentes (art. 5º, LVI, da Constituição e art. 157, caput e §1º, do CPP).

Conforme se extrai dos autos, os guardas efetuaram a busca pessoal no réu alegando que ele correu, o que entenderam como suspeito. É notório que tal motivo está atrelado ao ponto de vista meramente pessoal dos policiais/guardas. Tal busca relatada pelos agentes de segurança pública ofende, de forma manifesta, o disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, que somente autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. E, este também é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que a percepção de nervosismo por parte dos agentes públicos não é elemento que autoriza a busca pessoal:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos.

2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

(STJ, Resp 1.961.459, 6ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 02/04/2022) Assim, o fato de uma pessoa apresentar suposto nervosismo em via pública não configura, de modo algum, e tampouco justifica a fundada suspeita exigida pelo art. 240, §2º, do CPP, que deve ser entendida como a existência de indícios concretos de cometimento de crime, e não meras suposições pessoais de policiais/guardas civis. É inevitável, portanto, reconhecer a ilicitude de todas as provas que deram origem ao flagrante, bem como todas em decorrência de tal ato, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP – teoria dos frutos da árvore envenenada, que determina que a ilicitude dessa prova originária contamina todas as outras provas que são dela originárias, e consequentemente, não havendo provas a serem consideradas, a absolvição por insuficiência probatória.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Eventual sentença de condenação estaria embasada nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos guardas; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Da mesma forma, o réu é primário e a quantidade de drogas não é exacerbada. Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Segunda-fase: atenuantes

Ainda que aumentada a pena-base, é certo que o acusado é menor de 21 anos, motivo pelo qual faz jus à aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do CP.

Da mesma forma, a confissão deve ser considerada (art. 65, III, d, CP).

Isso posto, a pena-base, se aumentada na primeira fase deve retornar ao mínimo legal.

c) Aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo, sendo certo que, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

Ainda, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o afastamento do privilégio com base apenas na quantidade ou na qualidade da droga apreendida:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022. Informativo 731)

É o caso, portanto, de reconhecimento do privilégio, devendo a pena ser diminuída em seu grau máximo.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, reconhecido o privilégio, de rigor a fixação do regime inicial aberto.

Ainda que não aplicado o redutor do art. 33, §4º, da LD, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena

privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). O denunciado está respondendo ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais e não indica que se furtará ao processo. Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:
Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

GENILSON CELESTINO DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no 10 de fevereiro de 2022, por volta de 03h56, na rua Augusto Furlan, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, trazia consigo 59 porções de "crack", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis passavam pelo local, conhecido pelo "intenso tráfico de drogas", quando avistaram e suspeitaram do réu, que estava parado na via pública e ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga.

Após breve perseguição, feita abordagem de praxe, em poder do réu, numa "pochete" foram localizadas 59 porções de crack, além da quantia de R\$79,65, em espécie. Informalmente e perante a autoridade policial, o réu confessou o delito e alegou que "a droga é sua e estava vendendo para manter o vício, pois é usuário contumaz". Diante das circunstâncias apuradas, localização de droga em porções individualizadas em poder do réu e dinheiro de origem não comprovada, além de confissão, infere-se que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 85/86), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 87/88). Notificado (fls. 95), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva, bem como a manifestação do Ministério Público acerca da oferta de acordo de não persecução penal e, na recusa, envio os autos ao Procurador Geral de Justiça. No mérito, alegou inocência (fls. 99/104).

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao acordo de não persecução penal (fls. 108/119).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência e concedendo ao réu a liberdade provisória (fls. 120/124). O réu foi citado (fls. 148).

O Procurador-Geral de Justiça insistiu na recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal (fls. 165/174).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em debates orais, as partes se manifestaram. É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Arguiu a Defesa, que o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, com revista pessoal, não permitida aos guardas municipais, sem que houvesse flagrante.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

A Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, o réu foi abordado na posse da droga, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Note-se que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, correu caracterizando justa causa à abordagem, que ocorreu em via pública.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.

INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No presente caso, com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. IV - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,

providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. V - Quanto à pretensão de revisão da dosimetria da pena, referente à redução da basilar ao mínimo legal ou a patamar próximo, tem-se que melhor sorte não assiste ao paciente porquanto, em que pese a quantidade de drogas não ser tão relevante, tratando-se de "33 (trinta e três) porções de maconha, com peso líquido de 74,7g; 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 14,6g; 1 (uma) pedra de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 58,6g" (fl. 11), a sua diversidade e natureza extremamente destrutiva, em especial com relação ao crack, legitimam o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto), como realizado no édito condenatório e mantido pelo acórdão recorrido, ainda mais diante da existência de diversas anotações criminais, tendo o paciente sido preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021). 2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante. 3. O pleito de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecente demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, o que se não mostra viável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 6. No caso em tela, não foi reconhecida a incidência da minorante com base na dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo em vista a anterior prática de atos infracionais, com observância aos pormenores da situação concreta e respeitando os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.036/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Além disso, alegou a Defesa, também, que a prova é nula, na medida em que os guardas civis não poderiam abordar o réu, sem que houvesse flagrante percebido antes da abordagem.

Ocorre, contudo, que os guardas civis suspeitaram do réu que empreendeu fuga a pé e, tendo em vista que o ele se encontrava em via pública, ele foi abordado.

E mais, tratando-se de abordagem na via pública, há entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade de justa causa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO

DESPROVIDO. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais militares quando, ao avistar os agentes, correu para dentro de sua residência. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 3. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial" (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017). 4